



DIREITO CIVIL

Parte Geral

Prof. Me. Luís Fernando Almeida

E-mail: adv.luisfernandoalmeida@gmail.com

Cel.: (47) 99682-5798

Estrutura do Código Civil 2002



Manteve a inspiração do no modelo alemão, adotado pelo CC de 1916. A Parte Geral estabelece **normas aplicáveis a todos os ramos do Direito Civil**, tratando dos seguintes temas:

a) Pessoas naturais (arts. 1º a 39); b) Pessoas jurídicas (arts. 40 a 69); c) Domicílio (arts. 70 a 78); d) Bens e suas classificações (arts. 79 a 103); e) Fatos jurídicos (arts. 104 a 185); f) Atos ilícitos (arts. 186 a 188); g) Prescrição e decadência (arts. 189 a 211); h) Prova (arts. 212 a 232).

Estrutura do Código Civil 2002



Na parte especial dispôs sobre:

- a) Livro I – Do Direito das Obrigações: (arts. 233 a 965);
- b) Livro II – Do Direito de Empresa: (arts. 966 a 1195);
- c) Livro III – Do Direito das Coisas: (arts. 1196 a 1510);
- d) Livro IV – Do Direito de Família: (arts. 1511 a 1783);
- e) Livro V – Do Direito das Sucessões: (arts. 1784 a 2027);

Apresenta ainda um livro complementar que trata das disposições finais e transitórias: (arts. 2028 a 2046).

INÍCIO DA PERSONALIDADE E CAPACIDADE CONDICIONADA



O art. 1.º do Código Civil estabelece que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.

Isto quer dizer que todo ser humano tem capacidade plena para adquirir direitos ou obrigações.

Por capacidade plena, entretanto, entenda-se a capacidade de direito, ou seja, não se confunde esta com a capacidade de exercício ou de exercer os direitos, que somente se dará mediante o acréscimo de algumas condições.

INÍCIO DA PERSONALIDADE E CAPACIDADE CONDICIONADA



Importante dizer que, segundo a norma legal, o sujeito, desde que tenha personalidade (o que se verá adiante), tem capacidade plena para adquirir direitos e obrigações, mas somente terá capacidade plena para exercê-los mediante o implemento de alguns requisitos, como, por exemplo, a maioridade.

O Código Civil afirma que a personalidade civil somente tem início a partir do nascimento com vida (art. 2º), entretanto, de acordo com o mesmo dispositivo, a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro (ser concebido mas ainda não nascido).

INÍCIO DA PERSONALIDADE E CAPACIDADE CONDICIONADA



A aparente contradição de termos do art. 2.º do Código Civil põe em xeque a interpretação literal de sua primeira parte, que há muito está arraigada na doutrina que adota a chamada teoria natalista, pela qual a personalidade civil começa somente a partir do nascimento com vida.

Assim, podemos elencar, basicamente, três teorias que explicam o momento de início da personalidade civil: Teoria natalista; Teoria concepcionista; Teoria da personalidade condicionada.

INÍCIO DA PERSONALIDADE E CAPACIDADE CONDICIONADA



a) Teoria natalista: Resulta da interpretação literal do art. 2.º do Código Civil, resultando daí que a pessoa natural só adquire direitos a partir do momento em que nasça com vida, embora a lei ponha a salvo esses direitos (futuros) desde a concepção.

Dentre outros, podemos citar, como adeptos dessa teoria Sílvio Rodrigues, Sílvio Venosa e, com ressalvas, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho.

INÍCIO DA PERSONALIDADE E CAPACIDADE CONDICIONADA



b) Teoria concepcionista: sustentada, dentre outros, por Clóvis Bevilacqua, Silmara Chinelato e Almeida, Cristiano Chaves de Farias, Nélon Rosenvald, Carlos Roberto Gonçalves e Francisco Amaral Santos, a teoria concepcionista supõe que a personalidade jurídica da pessoa natural começa a partir da concepção, donde resulta concluir que, uma vez adotado, tal sistema afirma que o nascituro, ainda antes de nascer já adquire direitos.

INÍCIO DA PERSONALIDADE E CAPACIDADE CONDICIONADA



c) Teoria da personalidade condicionada: Considera-se que o nascituro tem personalidade desde a concepção, mas se trata de personalidade sujeita a uma condição suspensiva, qual seja, o nascimento com vida.

E, de fato, uma condição, pois o nascimento com vida, é evento futuro à concepção e incerto, pois a gestação pode ser interrompida por fatores diversos ou o feto pode, ainda, nascer morto (natimorto) hipótese em que, não implementada a condição, não adquiriu personalidade, muito menos direitos e obrigações. São adeptos desta linha, dentre outras, Arnoldo Wald, Serpa Lopes.

INÍCIO DA PERSONALIDADE E CAPACIDADE CONDICIONADA



À exceção da teoria concepcionista, qualquer dos dois outros sistemas adotados implica em que o nascituro, enquanto ainda não nascido, não adquire, de fato, direitos; se chega a nascer com vida, ainda que viva poucos minutos ou segundos, adquirirá direitos, como no exemplo dado por Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona:

"se o recém nascido - cujo pai já tenha morrido -falece minutos após o parto, terá adquirido, por exemplo, todos os direitos sucessórios do seu genitor, transferindo-os para sua mãe. Nesse caso, a avó paterna da referida criança nada poderá reclamar" (2004, p. 90).

INÍCIO DA PERSONALIDADE E CAPACIDADE CONDICIONADA



Por outro lado, embora o Código pareça, efetivamente, ter refutado a teoria concepcionista, não há como negar que o nascituro adquire, de fato, vários direitos, principalmente os chamados direitos da personalidade (basta lembrar o direito à vida, já que o aborto é crime tipificado pelo Código Penal), mas também tem outras prerrogativas, como a de receber doação (Código Civil, art. 542), legado ou herança, com direito a curador (CPC, arts. 877 e 878), do direito ao reconhecimento da filiação (CC, art. 1.609, parágrafo único) e, ainda, suplemento financeiro para garantir a sua subsistência na vida intrauterina, garantida pela Lei 11.804/08 (lei dos alimentos gravídicos).

INÍCIO DA PERSONALIDADE E CAPACIDADE CONDICIONADA



Para solucionar a questão, não vemos outra explicação que não seja, afinal, reconhecer a da personalidade condicionada, porque:

1) não há como negar que o nascituro merece proteção jurídica e encontra, de fato, na lei, vários atributos, principalmente no que se refere aos direitos da personalidade;

INÍCIO DA PERSONALIDADE E CAPACIDADE CONDICIONADA



2) por outro lado, a lei não garante, de plano, aquisição de direitos patrimoniais ao nascituro, mas apenas fornece formas de assegurar a sua aquisição para após o nascimento com vida, como a aceitação da doação por seus representantes, nomeação de curador para defender seus (futuros direitos) etc;

3) se ainda não adquiriu os direitos, mas os pode adquirir, inclusive podendo defender o direito eventual, através de terceiros, não há como deixar de admitir a personalidade ao nascituro, mas esta se encontra condicionada (com exceção dos direitos personalíssimos) ao nascimento com vida.

INÍCIO DA PERSONALIDADE E CAPACIDADE CONDICIONADA



O Supremo Tribunal Federal, todavia, adotou, de certa forma, a teoria natalista, ao julgar a ADI 3510/DF, quando, pelas palavras do Ministro Aires Brito, afirmou que:

"o Magno Texto Federal não dispõe sobre o início da vida humana ou o preciso instante em que ela começa. Não faz de todo e qualquer estágio da vida humana um autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é própria de uma concreta pessoa, porque nativiva (teoria "natalista", em contraposição às teorias "concepcionista" ou da "personalidade condicional")".

CAPACIDADE DE EXERCÍCIO



Incapacidade absoluta - Já vimos que a lei assegura a toda pessoa a capacidade de direitos e deveres na ordem civil. Como pudemos observar, esta capacidade, assegurada pelo art. 1.º do Código Civil, é somente de direito, ou seja, não envolve a capacidade de exercer os direitos.

Para que a pessoa adquira a capacidade de exercício, é necessário que preencha o implemento de algumas condições legais (art. 3.º). Em verdade, a verificação de tais condições se dá pela observância da ausência de algumas circunstâncias, quais sejam, aquelas que atribuem ao sujeito a incapacidade absoluta ou relativa.

CAPACIDADE DE EXERCÍCIO



Incapacidade absoluta - Não têm capacidade de exercício, portanto, aqueles a quem a lei diz serem absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil.

De acordo com o art. 3.º do Código Civil, estes são os menores de dezesseis anos.

Pode-se dizer que a incapacidade absoluta decorrente da menoridade é plena.

CAPACIDADE DE EXERCÍCIO



Incapacidade relativa

São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer:

- I- os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
- II - os ébrios habituais e os viciados em tóxicos;
- III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;
- IV - os pródigos.

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.

CAPACIDADE DE EXERCÍCIO



Incapacidade relativa

A incapacidade relativa deriva da preocupação do legislador de conferir a certas pessoas a proteção de outras, ou seja, conquanto aquelas já tenham condições de praticar os atos da vida civil, devem ser assistidas por estas, para que não sejam lesadas em função de sua inexperiência ou situação peculiar.

CAPACIDADE DE EXERCÍCIO



Incapacidade relativa - A doutrina tem admitido que a expressão "incapazes relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer" quer dizer que, com relação à prática de alguns atos, ou ao exercício de certos direitos, os relativamente incapazes podem praticá-los sem necessidade de autorização ou assistência.

Entretanto, tal interpretação defluía da letra do art. 84 do código revogado. Tal dispositivo determinava, expressamente que, somente nos atos determinados pelo código, o relativamente incapaz necessitaria da assistência.

CAPACIDADE DE EXERCÍCIO



Incapacidade relativa - O novo código não conta com dispositivo igual ou semelhante, razão pela qual a interpretação, agora, deve ser diferente.

Em verdade, ainda persistem alguns casos em que as pessoas relativamente incapazes podem praticar atos da vida civil, entretanto, no novo ordenamento, não mais se fala que eles somente necessitarão de autorização quando houver expressa previsão, mas, diz-se justamente o contrário, ou seja, os relativamente incapazes não necessitarão da autorização quando tal for expressamente previsto pelo código (exemplo: mandato -art. 666).

CAPACIDADE DE EXERCÍCIO



Incapacidade relativa - Tem sido motivo de debates a aplicação da nova regra de maioria para outros efeitos, como, por exemplo, a aplicação das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (os arts. 2º, parágrafo único e 121, § 5.º da Lei 8.069/90 permitem a aplicação de seus preceitos e da pena de internação até os vinte e um anos).

Creio que não há que se estender os efeitos da modificação para tais situações, porquanto, como já vimos, *lex specialis derogat lex generalis*.

CAPACIDADE DE EXERCÍCIO



Incapacidade relativa - O Estatuto da Criança e do Adolescente é lei de caráter especial ao Código Civil e, por outro lado, quando previu que algumas de suas disposições poderiam ser aplicadas até os vinte e um anos, já tinha em mente a maioridade penal aos dezoito anos, portanto, não se mostra incompatível com o novo regramento do art. 4.º, I.

O mesmo se diga quanto à prescrição penal pela metade em favor dos maiores de dezoito e menores de vinte e um anos (Código Penal, art. 115).

CAPACIDADE DE EXERCÍCIO



Incapacidade relativa - O mesmo, entretanto, a meu ver, não se aplica quanto à necessidade de nomeação de curador para o réu menor de vinte e um anos no Processo Penal, eis que, neste caso, a lei visava justamente a nomeação de pessoa que representasse o menor relativamente incapaz no processo criminal, algo que não persiste, porquanto não existe mais a dita menoridade.

As pessoas relativamente incapazes deverão ser assistidas pelos representantes legais. Os menores pelos pais ou tutores. Os demais pelos curadores. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial (art. 4.º, parágrafo único).

ESTADO DA PESSOA NATURAL



O estado da pessoa natural é, também, importante característica de sua individualização, pela qual se identifica a pessoa nos âmbitos político, familiar e individual.

Quanto ao estado político, esclarecem GAGLIANO e PAMPLONA que é uma "**categoria que interessa ao Direito Constitucional, e que classifica as pessoas em nacionais e estrangeiros**".

Quanto ao estado familiar, a pessoa será considerada:

ESTADO DA PESSOA NATURAL



a) quanto ao matrimônio: casada, solteira, viúva, divorciada ou separada judicialmente. A esse respeito, aliás, grassa a divergência doutrinária quanto à manutenção do estado civil das pessoas separadas, mas ainda não divorciadas, em função da Emenda Constitucional 66/2010, que aboliu a separação judicial e possibilitou a dissolução do casamento simplesmente pelo divórcio, independentemente de prévia separação judicial por um ano ou de fato por dois anos. Apesar de a separação judicial ter sido abolida pela nova ordem constitucional, aqueles já separados (mas ainda não divorciados) ao tempo da emenda preservam a prerrogativa de se manterem nesse estado enquanto for de seu interesse.

ESTADO DA PESSOA NATURAL



b) quanto ao parentesco: Temos parentes por:

- 1) consanguinidade (ascendentes, descendentes, irmãos etc) ou por afinidade (sogros, cunhados);
- 2) parentesco na linha reta (ascendentes, descendentes, sogros) ou colateral (irmãos, tios, primos, cunhados etc).

ESTADO DA PESSOA NATURAL



Quanto ao estado individual, a pessoa será considerada de acordo com o seu poder de agir ou de praticar os atos da vida civil, podendo ser, portanto:

- a) menor ou maior;
- b) capaz ou incapaz;
- c) homem ou mulher.

ESTADO DA PESSOA NATURAL



Quanto classificação de homem ou mulher:

Deve-se observar que a consideração do sexo ocorre não para se conferir mais ou menos direitos a um ou a outro, mas para se verificar: a) a legitimidade para a prática de determinados atos (assim, não existe casamento entre pessoas do mesmo sexo; o marido necessita de autorização da esposa para alienar bens imóveis nos regimes de comunhão de bens e vice-versa etc); b) a designação em atos da vida civil, dizendo, portanto, marido, mulher, cônjuge varão, cônjuge virago etc.

ESTADO DA PESSOA NATURAL



Cessação da incapacidade

A menoridade cessa aos 18 (dezoito) anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Cessará, para os menores, a incapacidade:

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;

ESTADO DA PESSOA NATURAL



Cessação da incapacidade

II - pelo casamento;

III - pelo exercício de emprego público efetivo;

IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;

V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria.

ESTADO DA PESSOA NATURAL



Estes são os modos de cessação da incapacidade, previstos pelo Código Civil.

No entanto, o código contemplou no art. 5.º, parágrafo único, apenas os casos de aquisição de capacidade pelos menores, ou seja, não tratou da cessação da incapacidade daqueles indivíduos considerados incapazes, ainda que maiores de idade (enfermos, deficientes mentais, pródigos, ébrios, etc.).

ESTADO DA PESSOA NATURAL



Entretanto, para quando tais pessoas deixarem de possuir as causas que determinaram sua incapacidade ou interdição, a solução é encontrada no art. 1.186 do Código de Processo Civil, que reza, *in verbis* que:

"levantar-se-á a interdição, cessando a causa que a determinou", todavia, o levantamento da interdição, ou cessação da incapacidade, somente se dará de forma judicial, ou seja, da mesma forma em que se deu a declaração da incapacidade.

MORTE PRESUMIDA



Diz o art. 6º, que a morte poderá ser presumida, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva.

Devemos diferenciar, entretanto, a ausência da morte presumida.

A ausência ocorre quando uma pessoa desaparece de seu domicílio, sem que dela ninguém tenha notícia, ou sem que tenha deixado representante ou procurador a quem caiba administrar seus bens.

MORTE PRESUMIDA



Pois bem, a ausência é instituto que se destina a **regular a administração dos bens do ausente**. Caso alguém seja declarado ausente, poderá haver a sucessão provisória de seus bens. **Dez anos depois de concedida a abertura da sucessão provisória, poderá ocorrer a sucessão definitiva dos bens do ausente.**

Somente quando for possível a sucessão definitiva dos bens do ausente é que ele poderá ser presumido morto. **Isto quer dizer que a ausência pode acarretar a conclusão pela morte presumida do ausente.**

MORTE PRESUMIDA



Entretanto, a morte presumida não se resume aos casos em que o indivíduo é declarado ausente.

O art. 7.º do Código Civil diz que pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência:

Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida; se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra.

MORTE PRESUMIDA



Para ambos estes casos, a morte presumida será declarada judicialmente, mas somente depois de esgotadas as buscas e averiguações no sentido de se constatar fisicamente a morte, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento.

Em resumo, **a ausência acarretará a presunção de morte**, quando puder ser aberta a sucessão definitiva, mas **a morte presumida nem sempre**, a partir do novo código, decorrerá da declaração da ausência, pois pode decorrer das hipóteses acima descritas.

COMORIÊNCIA



Ocorre comoriência quando dois ou mais indivíduos falecem na mesma ocasião e é impossível determinar-se qual deles morreu primeiro, quando, então, presume-se que eles faleceram simultaneamente (art. 8.º).

Destarte, se tais pessoas morreram simultaneamente, não ocorreu, entre elas, transmissão de direitos, como, por exemplo, no caso de ser uma herdeira da outra.

COMORIÊNCIA



A teoria da comoriência nem sempre teve aceitação no direito. No Direito Romano existiam presunções diversas, determinadas de acordo com o sexo e a idade dos que morreram na mesma ocasião.

O Código Civil francês, de 1804, também contemplava algumas destas presunções, ao invés da presunção genérica da comoriência. Entretanto, desde o código de 1916, o legislador brasileiro preferiu optar pela presunção genérica de morte simultânea, porque mais simples e menos especulativa.

COMORIÊNCIA



Veja-se o seguinte julgado:

Falecimento do marido e da mulher em mesmo desastre. Se o marido e a mulher falecem ao mesmo tempo, não haverá transmissão de direitos entre eles. E que os direitos a serem transmitidos não encontrariam sujeito para os receber. Assim, o pecúlio previdenciário do marido é desde logo atribuído a seus dependentes ou ascendentes, sem contemplação aos da esposa, porque ela não sobreviveu a ele (RT 659/146).

COMORIÊNCIA



Importante frisar, também, que, diante do estabelecimento da presunção de comoriência, pela lei, esta, por ser juris tantum, somente pode ser desconsiderada em caso de prova inequívoca em contrário.

A comoriência não se presume automaticamente: é necessária a impossibilidade de comprovar a ordem das mortes. Havendo prova de que uma pessoa faleceu antes da outra, não se aplica a comoriência, e a sucessão ocorrerá normalmente. O instituto afasta a chamada sucessão em cadeia.

REGISTRO PÚBLICO DAS PESSOAS NATURAIS E AVERBAÇÃO



O art. 9.º sujeita ao registro público:

I - os nascimentos, casamentos e óbitos;

II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz;

III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa;

IV-a sentença declaratória de ausência e de morte presumida.

REGISTRO PÚBLICO DAS PESSOAS NATURAIS E AVERBAÇÃO



O art. 10 do Código Civil determina a averbação, em registro público, dos seguintes atos:

I - das sentenças que decretarem a nulidade ou a anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal;

II - dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação (ex.: reconhecimento de paternidade);

III - dos atos judiciais ou extrajudiciais de adoção.

REGISTRO PÚBLICO DAS PESSOAS NATURAIS E AVERBAÇÃO



Enquanto o registro é ato que visa afirmar ou negar a existência, estado e capacidade da pessoa (exs.: nascimento, óbito, casamento, emancipação, interdição), a averbação é ato que visa modificar ou cancelar o próprio registro.

Por exemplo, quando se averba, no registro civil do casamento, a sua anulação, estar-se-á cancelando esse registro. Por outro lado, quando um pai reconhece o filho, far-se-á a averbação no seu registro de nascimento, provocando, assim, a sua modificação, pois, onde não tínhamos a anotação da filiação paterna, passaremos a tê-la.